



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיק 260/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
בתל - אביב

- התובעים:
1. אלון מורן  
מרח' אהרונוביץ' 7, תל אביב
  2. נציגות הבית המשותף ברח' אהרונוביץ' 7 תל אביב  
ע"י חבר הנציגות אלון מורן  
מרח' אהרונוביץ' 7, תל אביב

- נ ג ד -

- הנתבעים:
1. איריס לוי ת.ז. 024050213
  2. איל לוי ת.ז. 022452825
- שניהם מרחוב אהרונוביץ' 7, תל אביב

## פ ס ק ד ין

### מבוא

התובע 1 הינו בעלים של דירה בבית שברחוב אהרונוביץ' 7 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 7091 חלקה 59 (להלן: "הבית").

התובעת 2 הינה נציגות הבית.

הנתבעים הינם הבעלים של דירה בקומה הרביעית בבית (תת חלקה 16) (להלן: "דירת הנתבעים").

לטענת התובעים הנתבעים השתלטו על גג הבית המהווה רכוש משותף ותפסו בו חזקה ייחודית ללא קבלת הסכמה של בעלי הדירות בבית. לטענת התובעים המדובר בהסגת גבול לרכוש המשותף ולפיכך עותרים הם לסילוק ידם של הנתבעים מגג הבית. לכתב התביעה צורף מכתב נלווה במסגרתו ביקשו התובעים ליתן סעדים גם בנוגע לשינויים מבניים שעשו הנתבעים בדירת הנתבעים - פתיחת דלת יציאה לגג והגדלת חלונות וכן סעדים בנוגע לנזקים שאירעו לאיטום הגג.

כבר זהו המקום לציין כי התובעים לא הוכיחו את הנזקים הנטענים לאיטום הגג, לא את עצם קיומם של הנזקים ולא את הכימות הכספי של נזקים אלו. בטיעוניהם בדיון מיום 06.09.10 זנחו התובעים עניין זה ולפיכך אינני נזקק לו.

טענות הנתבעים הם כי המדובר בתביעה פרטית של התובע 1 ולא נתקבלה החלטה כדין לצירופה של התובעת 2 כתובעת בהליך זה. לטענת הנתבעים הם עושים שימוש סביר בגג ואין הם מונעים שימוש כנ"ל מבעלי הדירות האחרים בבית ובכלל זה ישנה דלת כניסה לגג מחדר המדרגות ולבעלי הדירות בבית מפתח לדלת זו. הנתבעים רכשו את דירת הנתבעים במצבה כפי שהיא כיום, כולל פתח היציאה לגג ולא ביצעו כל



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיק 184/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
בתל - אביב

שינוי בפתחים אלו (למעט שיפוץ פנימי בדירה בלבד). כמו כן הנתבעים לא גרמו לכל נזק לגג או לאיטום ואין כל תלונות שהן מצד מי מהשכנים בנוגע לשימוש שנעשה בגג. לטענת הנתבעים בין הקודמים להם בזכויות בדירת הנתבעים - ה"ה קריסטל (להלן: "קריסטל") לבין התובעים התנהל הליך קודם והצדדים הגיעו להסדר במסגרתו נותרו הפתחים מהדירה לגג, כפי שהם כיום. לטענת הנתבעים הם אלו אשר ביצעו איטום לגג ולא גרמו לו כל נזק.

מכתבי הטענות ונימוקי הצדדים עולה כי אין מחלוקת בין הצדדים כי הגג נשוא ההליכים דנן הינו רכוש משותף.

*הליכים משפטיים קודמים*

בטרם ניזקק לדיון לגופה של תביעה זו, יש הכרח לפרט את רקע ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין התובעת 2 לבין קריסטל בנוגע לדירת הנתבעים ובפרט ביחס לגג נשוא התביעה דנן והשימוש בו.

בין התובעת 2 לבין קריסטל התנהל הליך קודם בפני המפקחת הבכירה אריאלי בתיק 599/06 (להלן: "ההליך הקודם") שעניינו בדירת הנתבעים ובגג המשותף נשוא ההליכים דנן. במסגרת ההליך הקודם ניתן ביום 28.12.06 פסק דין אשר הורה לקריסטל להשיב את מצב הגג לקדמותו ובכלל זה להשיב את החלון לגודלו המקורי על פי תשריט הבית המשותף ולפנות את גג הבית כולל פינוי כל החפצים האישיים של קריסטל מהרכוש המשותף. בהתאם לפסק הדין הנ"ל נרשמה על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), על זכויות קריסטל הרשומות בלשכת רישום המקרקעין.

ביום 11.01.07 הוגשה על ידי הצדדים בקשה משותפת למחיקת ההערה שנרשמה על פי סעיף 130 הנ"ל לאחר שהצדדים הסדירו את הסוגיות ברכוש המשותף.

מכתב ההגנה של הנתבעים עולה כי בין התובעת 2 לבין קריסטל נחתם ביום 10.01.07 הסכם על בסיסו הוגשה הבקשה למחיקת ההערה כאמור (נספח ד' לכתב ההגנה) (להלן: "ההסכם"). בהסכם מסדירים הצדדים נושאים שונים שנפסקו בפסק הדין הנ"ל (הסרת דק העץ, פינוי חדר הכביסה וניתוק מרזב, תשלום כספים, פתיחת דלת היציאה לגג) אולם אין כל התייחסות לסוגיית החזרת הפתחים לגודלם על פי תשריט הבית המשותף.

**דיון**

השתלשלות ההליכים המשפטיים הקודמים מחייבת את הבדיקה האם לא חל במקרה דנן הכלל בדבר מעשה בי-דין.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיק 184/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
בתל - אביב

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)).

הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוזנר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 585-583; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיק 184/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
בתל - אביב

הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו],  
20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה  
בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) " (ההדגשה שלי, א.ס.).

הנתבעים דנן הינם חליפיהם של קריסטל בזכויות בדירת הנתבעים. לפיכך, משהוכרעה העילה שעניינה בדלת היציאה לגג והגדלת הפתחים מדירת הנתבעים אל גג הבית, הרי שאין לדון בעילה זו מחדש. משבחרה התובעת 2 להגיע להסדר עם קריסטל, לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם (נספח ד' לכתב ההגנה), ואף הסכימה למחיקת ההערה שנרשמה על פי פסק הדין בהליך הקודם, אין היא יכולה עתה לפתוח בהליכים חדשים, באותה עילה, כנגד חליפיהם של קריסטל. הוספתו של התובע 1 כתובע בתיק זה (כשלא ברור כלל מטיעונו האם הוא תובע באופן אישי או כיו"ר הנציגות) אין בה להכשיר דיון מחדש בעילה שהוכרעה בפסק דין סופי וחלוט.

בדיון מיום 06.09.10 התייצב מר אפוטקר, שהיה במועדים הרלבנטיים להליך הקודם ובמועד חתימת ההסכם חבר נציגות, וטען כי "מעולם לא ראיתי או חתמתי על כתב שאני מוותר על סגירת הפתחים והשבתם למצבם המקורי" (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 23-24 וכן בעמוד 5 לפרוטוקול שורות 11-12). יתכן ודברים אלו נכונים, אולם, ערכאה זו אינה מוסמכת בבדיקתם. ככל שנפלה טעות בזמנו או, חלילה, הטעיה, הרי שעל התובעת 2 לפעול בערכאות המתאימות בעניין זה כנגד המשיבים המתאימים. אולם, אין בכך לשלול תחולתו של הכלל בדבר השתק עילה לגבי ההליך דנן כאמור לעיל.

יוער כי מכתבי הטענות בהליך הקודם ניכר כי הפתחים עליהם דובר שם כי נפתחו על ידי קריסטל, זהים לפתחים הקיימים כיום בדירת הנתבעים. משכך, ממילא לא עלה בידי התובעים להוכיח את טענתם כאילו ביצעו הנתבעים את העבודות הנטענות בכתב התביעה.

הדברים האמורים אינם נכונים בכל הקשור לעילת התביעה שעניינה סילוק ידם של הנתבעים מהגג.

הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת". כך, בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב הענינים הפוגע..." (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם).

בספרות המשפטית נאמר כי: "הדין רואה עקרונית 'מעשה או מחדל כ'נמשכים' וכמולידים עילות תובענה מעת לעת, באותם מקרים בהם נתון הדבר בכוחו של העושה (או החדל) להפסיק מעשהו או מחדלו ובדרך זו שלא עוד לעשות עוולה או לגרום נזק ובלבד שאותה 'המשכיות' אינה נסמכת לאחור אל מעשה חד פעמי" (טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנזיקין, תורת הנזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7).

הסגת הגבול במקרה דנן איננה מעשה חד פעמי, אלא חוזרת היא מידי יום ובכוחם של הנתבעים להפסיקה. משכך, אין פסק הדין בהליך הקודם יכול להוות מעשה בי-דין מסוג השתק עילה בכל הקשור לשימוש הנתבעים בגג.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיק 184/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
בתל - אביב

פסק הדין בהליך הקודם גם אינו יכול להוות מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא מאחר ולא ברור באם השימוש אותו עושים הנתבעים דנן (הוא הפלוגתא העומדת להכרעה) זהה לשימוש אשר נאסר על קריסטל בהליך הקודם.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור כי השימוש שמבוצע על ידי הנתבעים בגג איננו מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

לא הוכח על ידי הנתבעים כי נתקבלה הסכמה של בעלי הדירות לשימושם בגג. אי התנגדות של שכנים, כנטען על ידי הנתבעים, אין בה די בהקשר זה. לפיכך, עלינו לבחון האם השימוש הינו רגיל וסביר במבחן תנאי הזמן והמקום כאמור.

גג הבית, בתנאי הזמן והמקום הרלבנטיים, לא נועד לשמש כמרפסת, מקום אחסון, מקום לבילוי ועריכת מסיבות או מקום למשחק ילדים, אלא אם הוגדר כך במפורש בתקנון הבית או בהסכמה של בעלי הדירות והוכשר יעודית מן הבחינה הפיזית לצורך זה. ייעודו של הגג הינו, לכל היותר, לשימוש למתקנים משותפים בבית ולהתקנת מערכות שונות, משותפות ופרטיות, בהתאם להוראות הדין (ר' למשל סעיף 59 לחוק המקרקעין) והחלטות בעלי הדירות.

השימוש בגג לצרכים האמורים כמרפסת, ללא התאמתו לכך מראש, מסוכן, הן מן הבחינה הפיזית (עלול לגרום לנזקים לאיטום הגג ולמערכות שונות המותקנות בו) והן מן הבחינה הבטיחותית (משחק על גג גבוה, ללא מעקה מוסדר וריצוף ובסמוך למתקנים ומערכות במותקנים בגג).

מרגע שהפך הגג לשמש כ"מרפסת" לדירת הנתבעים, ממילא הופך השימוש בו לבעלי הדירות האחרים בבית, על פי ייעודו כאמור לעיל, מוגבל ובעייתי, אם הוא בכלל אפשרי. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר מדירת הנתבעים קיים פתח יציאה ישירות אל הגג, אשר הוכרע כבר בהליך הקודם כי איננו תואם את הרשום בתיק הבית המשותף וניתן צו לסגירתו.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

תיק 184/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין  
בתל - אביב

יוצא, אם כן, כי הנתבעים יצרו לעצמם מרפסת גג לשימושם הייחודי. שימוש שכזה כמוהו כהצמדה בפועל של הגג לדירת הנתבעים השוללת לצמיתות את זכותם של בעלי הדירות לעשות שימוש בגג על פי יעודו.

קיומן של נקודות חשמל ומאור בגג, דבר שלא הוכחש על ידי הנתבעים כי אכן קיים, אך מחזק את הקביעה האמורה. עצם קיום המערכות הנ"ל בגג אינו עולה בקנה אחד עם "שימוש סביר" על פי המבחנים שלעיל ואין נפקא מינא בענין זה אם התאורה מאירה את הרכוש המשותף או מאירה את דירת הנתבעים בלבד.

בנוסף, קיים גם חשש כי השימוש בגג על ידי הנתבעים עשוי להביא לכך שגם אחרים יבקשו ל"נכס" לעצמם חלקים מן הרכוש המשותף לשימושם הבלעדי. כך פוסק בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאט נ. שיפר לז (2) 444).

לאור כל האמור אני סבור כי שימושם של הנתבעים בגג, בפרט כל עוד לא נסגר פתח היציאה הישירה מדירת הנתבעים אל הגג, איננו יכול להיחשב כשימוש סביר ומקובל ברכוש המשותף.

### סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה כאמור ואוסר על הנתבעים לעשות שימוש ייחודי בגג הבית ובכלל זה אני אוסר על הנתבעים לשים חפצים על הגג לרבות ריהוט (שולחן וכיסאות), שטיחים צמחיה וכיוצ"ב.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על זכויות הנתבעים בגוש 7091 חלקה 59 תת חלקה 16 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 260/10 בדבר איסור שימוש ייחודי בגג".

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים, בגין החזר הוצאות אגרת פתיחת ההליך, סך של 601 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה 28.06.10 ועד למועד התשלום בפועל וכן דמי בטלה בסך של 250 ₪ לתובע 1, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ח תשרי תשע"א, 06 אוקטובר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
בתל-אביב